

1500251-85.2022.8.26.0320

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500251-85.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-85.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2017511/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 22540925 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 4/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2017511 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2017511/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Endhrea Fernanda Nierengaten

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ENDHREA FERNANDA NIERENGATEN, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua João Ari Cason, nº 32, Jardim Gustavo Piccinini, nesta cidade e comarca, a acusada, em atividade de tráfico ilícito, vendeu e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 11 (onze) porções de cocaína, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar.

Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, a denunciada vendeu e tinha em depósito, em via pública, drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais civis se deslocaram ao endereço supra, onde situa-se um bar, conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas. Na ocasião, os agentes públicos visualizaram a denunciada em atitude suspeita e passaram a filma-la.

Seguidamente, a ré buscou porção de cocaína, entregou ao condutor de uma motocicleta, do qual recebeu dinheiro em troca. Inicialmente, o motorista se evadiu sem ser identificado. Logo depois, os policiais civis abordaram a denunciada, momento em que encontraram um telefone celular e uma nota de dez reais de posse dela, valor oriundo do tráfico.

Em continuidade à diligência, os agentes públicos encontraram onze porções de cocaína em um cano de águas de uma residência vizinha, onde a denunciada buscou droga para a venda da motocicleta retrocitado. Em seguida, ela foi presa em flagrante delito.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação da acusada para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 103/105).

A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2022 (fls. 121).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e a ré, interrogada ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defesa ofereceram alegações finais orais (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, rejeito a preliminar de flagrante preparado, que, se reconhecido, macularia, desde a primeira fase, a persecução penal.

A despeito da Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal, a situação delineada nos autos não se enquadra no flagrante preparado, hipótese de crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, que para seu reconhecimento, requer: a) provocação do agente; e b) impossibilidade da consumação do delito.

Os policiais civis, de acordo com a prova dos autos, resolveram se aproximar da ré, por suspeitar de sua conduta, havendo filmagem da ação delitiva. Outrossim, foram encontradas onze porções de cocaína escondidas no cano de água.

Delito permanente e de conteúdo múltiplo variado, que se tipifica, inclusive, pela guarda dos entorpecentes, também praticada pela ré, não se cogitando de ilegalidade no flagrante.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação com resultado positivo para "cocaína" (fls. 97/99 e 110/112), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada manteve o desejo de permanecer em silêncio (fls. 06/07).

Em Juízo, ela disse que tem 20 anos. É solteira. Atua como garota de programa. Fica no bar direto fazendo ponto de prostituição. As pessoas passam lá porque sabe que ela fica naquele local. Estava no bar. O motoqueiro a chamou para marcar programas para mais tarde. Depois tomou enquadro dos policiais civis. Não tem ciência do cano de água. Não viu os policiais localizando drogas no cano de água. Só viu os entorpecentes na delegacia. Não conhecia os policiais até então. Sabia que o local é ponto de tráfico de entorpecentes. Falou com um transeunte e com ele combinou o encontro. Um deles já tinha ido de manhã, ele só passou para confirmar a noite. Só chegou perto da motocicleta. Faz prostituição, mas não é por troca de drogas (mídia).

Sua versão é isolada e não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses dela.

A policial civil Jane Aparecida da Costa disse que o local é conhecido pela traficância. Há um bar que é ponto de venda de drogas. No dia em questão a ré estava lá. Estavam passando e viram uma venda a um transeunte. Pararam no quarteirão de cima e houve uma filmagem. O policial Ricardo viu aonde ela pegou as drogas para a venda a um motociclista. Ela tinha em seu poder dez reais e celular. No cano de água na rua, defronte a uma residência, foram encontrados onze pinos de cocaína. Indagada, ela nada disse. Viram nitidamente a venda a um transeunte. Quem filmou foi seu colega Ricardo. O motociclista não foi identificado. Havia um cano de água a cerca de dez metros da ré. Não havia mais pessoas perto do cano. Já tinha visto a ré naquele local e não havia nada contra ela. O dono do bar é Walter e há um processo contra ele por tráfico de drogas. Viram a ré passando drogas, a acusada mexeu para pegar as drogas. Não deu para abordar o motoqueiro, ele saiu pelo outro lado. O local não é ponto de prostituição (mídia).

O policial civil Ricardo Alfredo Coelho disse que se recorda da abordagem. O local é um ponto de venda bem conhecido. Viram a ré fazendo venda de drogas a um transeunte. Pararam na parte de cima do quarteirão. Filmaram a venda de drogas a um motociclista. A câmera ficou embassada. Havia onze pinos de cocaína no cano de água e foi lá que ela pegou para vender. Viram nitidamente que houve venda de drogas. As porções estava prontas para venda. Viu a ré no bar um dia antes, nunca havia abordado ela. Não sabe se lá é ponto de prostituição. Há mais de dez anos esse local é ponto de drogas. O trabalho deles é combater o tráfico. Viram a acusada passando droga a um motoqueiro. Indagada, ela nada falou. No cano havia drogas e ela foi naquele local, pegou algo e entregou ao motoqueiro. Na filmagem ficou desfocado, mas viu perfeitamente a venda de droga. Não abordaram o motoqueiro porque ele saiu pela parte contrária, não deu tempo de abordar. A acusada tinha dez reais no bolso e um telefone (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10)." (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas duas testemunhas de defesa.

A testemunha Vanessa Aparecida Gabriel contou que é amiga íntima da ré. Foi ouvida como informante. Ficou sabendo que a acusada foi presa no bar. O local é perto da sua casa, costumam ir lá porque vai jovens. Nunca viu a ré vendendo drogas. Já viu outras pessoas efetuando comércio de entorpecentes. Tem conhecimento que a acusada faz programas sexuais, ela se encontra com os clientes naquele bar. A ré fica dentro do bar, os clientes param e solicitam os serviços dela. A ré pede para eles esperarem na esquina debaixo para não ficar constrangida. A acusada não faz entrega de cartões. Tem programa que ela ganha cem, duzentos reais. Tem dia que ela faz mais de cinco programas (mídia).

A testemunha Juliana Pereira Barbosa disse que tem muita amizade com a ré. Foi ouvida na condição de informante. Sabe que a acusada foi detida em um bar. Conhece o local, costuma ir lá com as amigas e a acusada. Nunca viu a ré vendendo drogas, mas chegou a ver outras pessoas efetuando o comércio. A acusada faz ponto nesse bar. Sua amiga faz uso de drogas. Explicou como a acusada mantém contato com os clientes. Eles buzina e ela sai, a ré gosta de guardar sigilo. É lá fora que ela marca os encontros. Menos de cem reais ela não ganha. Acredita que eram em torno de cinco programas por dia que sua amiga fazia (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais civis faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico, quando avistaram a acusada vendendo drogas para o condutor de uma motocicleta, dele recebendo quantia em dinheiro. A ação foi filmada, eis que antes a ré foi vista mantendo contato com um transeunte.

Diante da fundada suspeita, abordaram a acusada. Em revista pessoal foi encontrada a quantia de R\$10,00 (dez reais) oriunda da venda ilícita de entorpecentes.

Em seguida, os agentes públicos encontraram onze porções de cocaína em um cano de águas de uma residência vizinha, onde a ré buscou droga para a venda ao motociclista. Após, ela foi presa em flagrante delito, não dando qualquer explicação.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias e o local da prisão, assim como o depoimento incriminador dos policiais civis, tudo a apontar a acusada como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos policiais civis quanto ao tráfico de drogas.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de

entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardínópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

As duas testemunhas de defesa foram ouvidas na condição de informantes. Elas não presenciaram a prisão em flagrante, apenas mencionando que a acusada trabalhava como garota de programa. Nesse cenário, deve prevalecer o relato dos policiais civis que prenderam a ré em flagrante delito, havendo filmagem da ação delitiva.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra a acusada, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos

59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis à ré, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

É certo que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. No presente caso, todavia, haveria desproporção no aumento da pena-base, pois a pouca quantidade apreendida reflete elementos ínsitos ao crime, que já prescreve pena mínima em montante elevado (cf. STJ, HC 705.536/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; AgRg no RESp 1947327/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022; AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, sendo a ré primária, de bons antecedentes, não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

No caso em julgamento, observo que constam expedientes por atos infracionais (fls. 25 - execução de medida nº 0001318-38.2017.8.26.0320 e autos nº 0005424-77.2016.8.26.0320 - remissão com liberdade assistida por atos infracionais análogos ao artigo 180 do CP e artigo 28 da Lei de Drogas, fatos ocorridos em 13 de março de 2016 - consulta E-SAJ).

Apesar do entendimento deste Juízo no sentido de que atos infracionais constituem fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, os expedientes acima mencionados, por si só, não comprovam que a acusada integra organização criminosa ou se dedica desde então à atividades ilícitas, ainda mais quando decorrido considerável lapso temporal entre o ato infracional e o crime imputado (19/01/2022), não havendo razoável proximidade temporal com o delito de tráfico.

Nessa direção, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE AS DATAS DOS ATOS INFRACIONAIS E O CRIME IMPUTADO. (...) 3. Com efeito, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração." (EResp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 4. Hipótese em que

não se verifica, mesmo considerando a nova compreensão desta Corte Superior, a possibilidade do afastamento da causa especial de redução de pena, tendo-se em conta que o crime foi praticado em 4/1/2019, tendo o recorrido respondido por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, praticados em 23/8/2015 e 7/10/2016; e por ato infracional análogo ao crime de portar droga para o consumo próprio, praticado em 14/9/2016. cuidando-se, portanto, de condutas praticadas durante a menoridade penal, mas em um lapso temporal considerável da data do crime em julgamento. 5. Recurso especial improvido".(STJ, REsp 1881115/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021, grifo nosso).

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão (apreensão de 11 porções de cocaína pesando pesando 2,93 gramas).

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento da acusada, desde a polícia, bem como em juízo, leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

A benesse não é suficiente e nem eficaz à reprovação de sua conduta, além de não ser socialmente recomendável para a hipótese presente, pois insuficiente à sua ressocialização, já que descumpriu benefício processual.

De fato, a medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ENDHREA FERNANDA NIERENGATEN, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Em razão da pena ora aplicada, poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária da acusada e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome da acusada deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA